

1501894-61.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... primário, está sendo denunciado pela prática de tráfico de drogas, conforme se verifica nos autos 1500063-12.2020.8.26.0628, pois em 12/01/2020 foi surpreendido na Favela do Quiabo na posse de 67 porções de maconha, 182 de cocaína e 63 de crack.

E o réu JOÃO VITOR também está sendo processado por ter, em tese, praticado tráfico de drogas juntamente com outro indivíduo, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501894-61.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501894-61.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264123/2021 - DEL.POL.COTIA, 20513362 - DEL.POL.COTIA, 3629/21/403 - DEL.POL.COTIA, 2264123 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DOS REIS SABINO DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

WELLINGTON DOS REIS SABINO DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR SILVINO DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 115/116).

Oferecida a denúncia (fls. 114), esta foi recebida (fls. 125/126) e os requeridos citados.

Após a apresentação de defesas escritas (fls. 168/170 e 174/179) o recebimento da

denúncia foi ratificado (fls. 188/189).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados, de fato, praticaram o delito que lhes é imputado, com ressalva da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, que recai sobre os réus, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelos laudos químico toxicológico (fls. 13/15 e 235/237), que atestam pelo resultado positivo para maconha, pelo relatório final (fls. 86/88), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Militares Vanderlei dos Santos Araújo e Daniel Pereira Noda, quando inquiridos em juízo, disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram em veículo Siena, de cor preta, com três indivíduos.

Quando perceberam a presença policial, os indivíduos tentaram se desvencilhar da abordagem, aumentando a velocidade do automóvel. Momentos depois conseguiram realizar a abordagem.

Em busca pessoal não encontraram nada de ilícito. No entanto, nas buscas realizadas no automóvel localizaram 04 tijolos de maconha, que estavam sobre o banco traseiro do veículo.

Indagados, os indivíduos informaram que transportavam a droga de Osasco, do morro do socó, com destino a Itapevi, no morro do quiabo, sendo que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Não conheciam as pessoas abordadas. O menor estava no banco traseiro, ao passo que os imputáveis estavam nos dianteiros.

O Militar Vanderlei ainda pontuou que os acusados informaram que não era a primeira vez que realizavam o traslado de drogas.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições relevantes, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

O réu JOÃO VITOR, quando interrogado em juízo, disse que pretendia adquirir as drogas para consumo pessoal e WELLINGTON e o menor o dariam carona. Eles não sabiam da existência da droga.

Informou que adquiriu 5 quilos de maconha para consumo pessoal e que não pagou nada pela droga. Não sabe porque lhe deram a droga.

Por fim, disse que não conhecia os policiais.

O acusado WELLINGTON, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime, relatando que no dia dos fatos estava em uma festa e, quando retornava para sua casa, a mulher de João Vitor pediu para que o buscasse, pois não havia ônibus disponível, e que João Vitor colocaria R\$ 40,00 de combustível.

Declarou que foi buscar João Vitor juntamente com o adolescente. No retorno foram abordados pelos policiais, sendo que na ocasião parou o veículo tão logo os militares ordenaram.

Asseverou que não tinha conhecimento acerca da existência da droga.

Pois bem.

A imputação Ministerial, quanto à tipicidade da conduta dos acusados, é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que os réus, de fato, estavam a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte dos réus, na medida em que tinham em depósito e transportavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes, em considerável quantidade, eram levados pelos réus, que os detinham especialmente para o fim de cometer a traficância, notadamente porque confessaram aos agentes da lei quando da abordagem.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram uníssonos e harmônicos ao descreverem as diligências realizadas durante o ocorrido.

Por outro lado, as versões apresentadas pelos acusados não encontram integral respaldo nos autos, especialmente a do corréu João Vitor, não sendo o mínimo crível que ele simplesmente ganhou cinco quilos de drogas para o seu consumo e sequer sabe o motivo pelo qual recebeu gratuitamente expressiva quantidade de entorpecentes.

Ademais, destaca-se que "os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo suas condenações quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

A única ressalva, portanto, é respeitante à incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Isso porque, malgrado o crime tenha sido praticado enquanto instalado o estado da pandemia, não há qualquer elemento nos autos que indique que os acusados tenham se valido ou se beneficiado do estado de calamidade pública para a prática de infração penal.

Nesse sentido:

Apelação criminal - Furto qualificado e corrupção de menor - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas - Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas - Réu confesso - Depoimentos dos policiais militares robustos e coerentes - Acervo probatório consistente - Penas alteradas - Básicas reconduzidas aos mínimos legais, tendo em vista que as circunstâncias judiciais, tidas por desfavoráveis, não restaram demonstradas ao cabo da instrução criminal - Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porquanto, embora os crimes tenham sido realizados durante situação de calamidade pública, ocasionada pela pandemia do coronavírus, não restou apurado, na espécie, que o agente se beneficiou de tal circunstância para a consecução da empreitada delituosa - Reconhecimento do concurso penal entre as infrações penais, com a majoração da reprimenda corporal mais grave em 1/6 (um sexto) - Cabimento da substituição por restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais - Regime inicial modificado para o aberto, em caso de reconversão. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1501028-27.2020.8.26.0648; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Qualificadora da destreza comprovada pela robusta prova oral acusatória - Condenação mantida. Dosimetria - Redução da reprimenda - Exasperação da pena-base com esteio em processos não aptos para tanto - Reprimenda reduzida ao piso legal - Recurso parcialmente provido. Afastamento da circunstância agravante de ter o crime praticado em ocasião de calamidade pública - Ausência de comprovação de que o acusado se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia - Recurso parcialmente provido para este fim, sem reflexo na pena. Pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal - Inadmissão da Teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Regime aberto - Reincidência - Regime semiaberto mantido - Inteligência da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça.

(TJSP; Apelação Criminal 1507134-67.2021.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Furto simples (art. 155, caput, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas Policiais Militares. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Condenação imperiosa. Tentativa não caracterizada. Delito consumado, que se aperfeiçoa com o mero desapossamento do bem. Maus antecedentes e reincidência devidamente configurados. Inexistência de bis in idem. Agravante da calamidade pública. Não incidência, "in casu". Ausência do nexa causal entre o crime perpetrado e a pandemia vivenciada no País. Regime fechado único possível. Apelo parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1509114-49.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno WELLINGTON DOS REIS SABINO DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR SILVINO DE SOUZA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase da dosagem, majoro as penas dos acusados em 1/6 (um sexto), pois há de se anotar que a conduta dos requeridos é mais reprovável do que a normal à espécie.

Com efeito, a expressiva quantidade encontrada com os réus seria vendida em porções fracionadas, de sorte que atingiriam muitas pessoas.

Assim, suas culpabilidades, diante disso, são mais acentuadas.

Com efeito, tal entendimento foi confirmado no r. acórdão proferido nos autos de nº 0001381-11.2015.8.26.0360, com relação à sentença de lavra deste julgador:

“Em detida análise dos autos, de rigor o reconhecimento da pena-base acima do mínimo legal.

Ressalte-se que embora este Relator perfilhasse do entendimento que a quantidade da droga apreendida serviria para caracterizar o delito do tráfico de drogas, mas não era suficiente à exacerbação da pena-base, após minuciosa análise sobre o tema, filio-me ao entendimento de que a quantidade e natureza da droga, neste caso, recomendam a fixação acima do mínimo, o que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas.

O artigo 42, da Lei 11.343/06 prevê, de forma expressa, que na fixação das penas o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal: 'a quantidade da substância ou do produto', de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser considerado para agravar a pena.

Sobre o tema a seguinte jurisprudência:

'A natureza e a quantidade da droga são fatores que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.' (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, GJe 14/11/2011).

Porquanto, a quantidade de droga apreendida, frisa-se, justifica a exasperação da pena-base, assim como também entendeu o d. Magistrado a quo.” (TJSP - APELAÇÃO nº 0001381-11.2015.8.26.0360, 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Rel. Paulo Rossi, julgado em 19/10/2016).

Na segunda fase não há nada a ser considerado.

E, na terceira fase, considerando que os réus praticaram o crime juntamente com um adolescente, aumento suas penas em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Ainda, os acusados não têm direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Verifico que o réu WELLINGTON, malgrado seja primário, está sendo denunciado pela prática de tráfico de drogas, conforme se verifica nos autos 1500063-12.2020.8.26.0628, pois em 12/01/2020 foi surpreendido na Favela do Quiabo na posse de 67 porções de maconha, 182 de cocaína e 63 de crack.

E o réu JOÃO VITOR também está sendo processado por ter, em tese, praticado tráfico de drogas juntamente com outro indivíduo, na cidade de Osasco, conforme se depreende dos autos 1501877-60.2019.8.26.0542.

Isso demonstra que ambos os réus têm se dedicado a atividades criminosas.

Ademais, o fato de os requeridos terem praticado o ato em concurso indicam que estão efetivamente inseridos em atividade organizada, notadamente porque transportavam grande quantidade de entorpecente e informaram aos policiais que não era a primeira vez que realizavam o transporte de drogas.

Deveras, “porque diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo”.

De fato, de se notar que embora não tenha sido apurado indicativo acerca de eventual associação desenvolvida pelos réus, a atividade que eles desenvolviam estava nitidamente organizada, fato que aponta pela constância da prática delitiva.

Tais fatos demonstram que os acusados têm se dedicado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável

discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)". (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego à pena total e definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para cada réu.

O regime inicial do cumprimento de pena de ambos os acusados é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada, da quantidade de drogas e diante dos veementes indicativos de que os acusados estão incisivamente inseridos na traficância.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente



insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direito" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Com efeito, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não garante que seja o real proprietário do bem, notadamente porque a propriedade de bem móvel se transfere com a mera tradição.

Ademais, o mero fato de o automóvel ter sido utilizado para a prática da empreitada criminosa é suficiente para que seja declarado perdido, não havendo, neste caso, que se arguir eventual direito de terceiro de boa-fé, pois ao se emprestar o bem a alguém, o proprietário (se se considerar que pertence a terceiro) está passível de perder o automóvel caso ele seja empregado em atividade ilícita.

Dessa forma, é evidente que o réu utilizava o bem para o fim específico de transportar entorpecentes.

Deveras, “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Diligencie a serventia para que o automóvel referido nos autos seja destinado às entidades ou órgãos competentes, oficiando-se.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor, apenas se nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P.I.C.

Cotia, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA